

次の【事例】及び【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。

【事例】

Aは、殺意をもって、Bを狙い、けん銃を発射したところ、その弾丸がBを貫き、たまたまBの背後を通行中のCにも命中したが、B、C共に死亡しなかった。なお、Aは、けん銃を発射した時点で、Cの存在を認識していなかった。

【見解】

犯罪の故意があるとするには、罪となるべき事実の認識を必要とするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが必ずしも具体的に一致することを要するものではなく、両者が法定の範囲内において一致することをもって足りる。人を殺す意思のもとに殺害行為に出た以上、犯人の認識しなかった人に対してその結果が発生した場合にも、その結果について殺人の故意があり、Bに対する所為についてはもちろんのこと、Cに対する所為についても殺人未遂罪が成立し、両罪は観念的競合となる。

【記述】

1. この【見解】によれば、甲が殺意をもって、乙を狙い、けん銃を発射したところ、弾丸が乙に命中したが、乙は死亡せず、乙を貫通した弾丸が甲が予期しなかった丙に命中して丙が死亡した場合、甲には、丙に対する殺人既遂罪が成立するが、乙に対する犯罪は成立しない。
2. この【見解】によれば、甲が殺意をもって、乙を狙い、けん銃を発射したところ、弾丸が乙に命中して乙が死亡し、乙を貫通した弾丸が甲が予期しなかった丙にも命中して丙も死亡した場合、甲には、乙に対する殺人既遂罪、丙に対する過失致死罪が成立する。
3. この【見解】に対しては、殺人罪は被害者ごとに成立する犯罪であるから、被害者の個性は構成要件的に重要な事実であるとの批判がある。
4. この【見解】に対しては、いわゆる客体の錯誤の場合と方法の錯誤の場合とで故意の有無について結論が異なるのは不合理であるとの批判がある。
5. この【見解】に対しては、1人を殺す故意しかないのに、1人を殺した場合より処断刑が重くなるのは妥当ではないとの批判がある。

No.46	錯 誤	正答率
H25-19	正 解	88%

設問の見解は、AにB及びCに対する殺人未遂罪の成立を認め、両罪は観念的競合（54条1項前段）となるとしている。この見解は、法定的符合説及び数故意犯説である（最判昭 53.7.28、百選 142 事件参照）。

1 誤っている

法定的符合説によれば、乙も丙も構成要件上は同じ「人」であり、甲が乙の殺害を認識した以上は、殺人の実行行為における客体の認識として欠けるとはなく、丙に対する故意が認められる。また、数故意犯説によれば、乙に対する故意も、丙に対する故意も認めることができる。よって、甲には丙に対する殺人既遂罪が成立するとともに、乙に対する殺人未遂罪が成立する。

2 誤っている

甲は殺意をもって乙を狙いけん銃を発射したところ、乙に命中した弾丸が更に丙にも当たり、乙及び丙が死亡した場合、甲は1個の殺人の故意で2個の殺人の結果を生じさせたといえ、故意の個数が問題となる。この場合、数故意犯説を採れば、法定的符合説からも、乙だけでなく丙に対しても殺人罪（199条）の成立を肯定し得る。

3 正しい

法定的符合説に対しては、法定的符合説と同様に構成要件該当事実を構成要件要素のレベルで抽象的に捉えることを認めつつ、法益主体の個別性・具体性を捨象できないとする立場（具体的符合説）から、殺人罪は被害者ごとに成立する犯罪であるから、被害者の個別性は構成要件的に重要な事実であるとの批判がある。

4 誤っている

法定的符合説によれば、例えばXと思って殺したところ実はYであったときのように（人違い）、客体について誤認がある客体の錯誤の場合、Yについての故意が認められる。また、法定的符合説及び数故意犯説によれば、Xを狙って発砲したところ意外のYに命中してYが死亡したというときのように（手違い）、行為の結果が認識内容と異なる客体に生じた方法の錯誤の場合、X及びYの複数の客体について故意が認められる。

5 誤っている

法定的符合説及び数故意犯説によれば、数個の故意を認めることができ、その罪数関係は観念的競合となる。罪数関係が観念的競合となるのであれば、科刑上は1個の罪として扱われるから、処断上格別の不利益はない。そのため、1人を殺す故意しかないのに、1人を殺した場合より処断刑が重くなるということにはならない。